Le test du tiers indiscret

Droit anglais des contrats | Officious bystander test | Clause implicite de fait

Imaginez qu'un tiers interrompe la négociation et propose la clause précise qui fait aujourd'hui l'objet du litige. Appréciée objectivement à l'époque, aurait-elle paru évidente aux deux parties ? C'est l'idée de l'exemple donné par le juge MacKinnon dans *Shirlaw*.

1. Interpréter d'abord les stipulations expresses

Lisez les termes dans leur contexte contractuel. L'obligation envisagée peut déjà découler des stipulations expresses. S'il subsiste une lacune, précisez ce que la clause ajouterait et comment le contrat répartit déjà le risque en cause.

Ce test concerne les clauses implicites de fait. La loi, les usages et les règles attachées à une catégorie de contrats obéissent à leurs propres conditions.

2. Formuler une question précise

Soumettez la même clause concrète aux deux parties. Qui doit faire quoi, quand et dans quelles limites ? Une obligation générale de coopérer laisse trop de questions ouvertes si le différend porte sur l'accès, les délais ou le coût. Le tiers imaginaire pose la question. La question décisive est de savoir si les deux parties auraient répondu « Bien sûr ! ».

3. Apprécier l'évidence à la date de conclusion

Placez des personnes raisonnables dans la situation des parties à l'époque, à la lumière du contrat et de son contexte. La clause doit objectivement aller de soi pour les deux parties. L'attente exprimée plus tard par une seule partie a peu de poids à elle seule. La nécessité de négocier sa portée ferait douter de son évidence.

4. Appliquer un critère exigeant

Selon *Marks and Spencer v BNP Paribas*, la nécessité pratique et l'évidence sont deux critères alternatifs qui conduisent souvent au même résultat. Demandez si la clause est nécessaire au fonctionnement du contrat ou si elle va de soi. Elle doit pouvoir être formulée clairement et être compatible avec les stipulations expresses. L'équité ou la commodité ne suffisent pas à elles seules.

> Legal English | **Officious** qualifie une personne qui intervient sans y être invitée. **It goes without saying** signifie que cela va de soi.

Quatre décisions à comparer

Shirlaw v Southern Foundries | Un mandat à durée fixe

Shirlaw avait été nommé directeur général pour dix ans. Après une modification des statuts, il a été révoqué comme administrateur et a perdu sa fonction de directeur général. La Cour d'appel a retenu une clause implicite protégeant le mandat contre ce mode de rupture. Le juge MacKinnon a demandé comment les deux parties auraient réagi à la clause lors de la conclusion.

The Moorcock | Le fonctionnement pratique de l'accord

Un navire utilisant un quai a été endommagé en touchant le fond à marée basse. La Cour d'appel a retenu une obligation de diligence raisonnable pour vérifier la sûreté du poste d'amarrage et avertir du danger le cas échéant. Cette obligation permettait l'usage convenu du quai. Sa portée était plus limitée qu'une garantie absolue de sécurité.

Marks and Spencer v BNP Paribas | Un bail détaillé

Un locataire commercial a payé le loyer d'avance puis exercé une faculté de résiliation anticipée. Il a demandé le remboursement de la période postérieure à la fin du bail. La Cour suprême a écarté la clause implicite de remboursement. Le bail fonctionnait sans elle. L'équité apparente d'un remboursement ne suffisait pas.

Barton v Morris | Une condition négociée

Un intermédiaire devait être rémunéré si un bien était vendu à un prix convenu. Le prix effectif était inférieur. La majorité de la Cour suprême a refusé d'inférer un droit à une rémunération raisonnable dans cette situation. Il fallait tenir compte de la répartition des risques prévue par l'accord.

> Lecture comparée | Comparez l'obligation limitée dans *The Moorcock* au remboursement demandé dans *Marks and Spencer*. Comment fonctionne chaque contrat sans la clause proposée ?

Cas pratique corrigé et sources

L’accès nécessaire aux essais

Une usine charge un ingénieur de tester des capteurs installés pendant un arrêt de deux jours fixé à l’avance. Le document signé précise les essais et les honoraires. Tous deux savent que seule l’usine peut délivrer les identifiants temporaires nécessaires et qu’aucun autre accès n’est disponible. L’ingénieur les demande à temps. L’usine refuse en invoquant le silence du contrat. Quelle clause implicite pourrait être retenue ?

Corrigé

Formuler une clause limitée. Sur demande présentée à temps, l’usine doit fournir l’accès temporaire raisonnablement nécessaire aux essais convenus pendant l’arrêt. Les règles ordinaires de sécurité restent applicables.

Interroger les deux parties à la conclusion. Les essais prévus et le créneau fixe indiquent fortement que l’accès allait de soi. Sans lui, l’ingénieur ne peut effectuer les essais, ce qui étaye aussi la nécessité pratique. Un accès permanent ou l’accès à des données étrangères aux essais exigerait une justification distincte.

Vérifier le texte. Recherchez les conditions de sécurité, les modalités d’accès et toute clause répartissant le risque de refus. Comparez ensuite la demande et la réponse de l’usine avec l’obligation précise.

> Variante | Le contrat permet expressément à l’usine de refuser les identifiants et prévoit à la place des essais supervisés sur site. L’obligation de délivrer les identifiants contredirait cet accord.

Jurisprudence de référence

Shirlaw v Southern Foundries (1926) Ltd [1939] 2 KB 206, 227 | Le test du juge MacKinnon

The Moorcock (1889) 14 PD 64 | Extrait cité au par. 22

Marks and Spencer plc v BNP Paribas [2015] UKSC 72, paras 14–31 | Critère actuel

Barton v Morris [2023] UKSC 3, paras 19–37 | Répartition expresse des risques